

1500192-57.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... droga apreendida era destinada ao tráfico. Ao Estado-acusador incumbe demonstrar a configuração do tráfico, que não ocorre pelo simples fato dos réus terem comprado e estarem na posse de entorpecente. Em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, cabe ao Ministério Público comprovar que o entorpecente era destinado ao tráfico. Não fazendo esta prova, prevalece a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,

Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500192-57.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2032576/2021 - Delegacia de Polícia de Alambari, 16044528 - DISE- DEL.SEC.ITAPETININGA, 5/21/322 - DISE- DEL.SEC.ITAPETININGA, 2032576 - DISE- DEL.SEC.ITAPETININGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO RICHARD BARBOSA FACHINI REGO

Aos 08 de março de 2022, às 16:30h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado. Presentes a defensora pública, Dr(a). Mariela Moni Marins Tozetto, e o DD. Promotor de Justiça Dr. Carlos Renato Ferreira Zanini. Ausente o acusado GUSTAVO RICHARD BARBOSA FACHINI REGO. Antes de iniciados os trabalhos pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decretada a revelia do réu e em seguida colhidos os depoimentos de 02

(duas) testemunhas de acusação, arroladas em comum com a defesa do réu. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: O réu foi denunciado como incurso no art. 33 "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na exordial, trazia consigo e guardava, para comercialização a terceiros, 03 (duas) porções de "maconha", com peso líquido de 2,54g (dois gramas e cinquenta e quatro centigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de constatação provisória de fls. 13/14 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 52/54. Oferecida denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida e o réu foi citado. Durante a audiência de instrução e julgamento as testemunhas foram ouvidas. Como o réu não compareceu ao ato, foi decretada a revelia e a instrução foi encerrada. É a síntese do necessário. Douto Julgador, o pedido deve ser julgado PROCEDENTE para CONDENAR o réu nos exatos termos propostos na denúncia. Narra a denúncia que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento, momento em que avistaram o denunciado, já conhecido nos meios policiais como traficante de drogas, mantendo contato e entregando algo ao motorista de um veículo. Ocorre que, ao perceber a presença da viatura, GUSTAVO prontamente dispensou algo ao chão, bem como o veículo empreendeu fuga. Diante disso, os policiais decidiram abordar o denunciado e, em revista pessoal, com ele encontraram o valor de R\$ 20,00 (vinte reais). Ato contínuo, ao analisarem o que GUSTAVO havia dispensado antes da abordagem, os policiais encontraram 03 (três) porções de "maconha". Indagado, o denunciado confirmou que estava comercializando as porções de droga por R\$ 10,00 (dez reais) cada uma. GUSTAVO foi preso em flagrante delito. Em razão das circunstâncias da apreensão das drogas, tais como o fato de GUSTAVO já ser conhecido como traficante de entorpecentes, a conduta do denunciado de manter contato com um carro e prontamente dispensar as drogas ao chão ao notar a presença da viatura, a forma de acondicionamento das drogas, já em porções individuais, prontas para a venda, quantia em dinheiro, além da confissão informal do denunciado, não deixam dúvidas de que os narcóticos se destinavam ao tráfico. A materialidade da infração penal está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação provisória e do laudo de exame químico-toxicológico. Quanto à autoria, também não restou a menor dúvida. A prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou o fato descrito da denúncia, fornecendo firme base para a prolação da sentença condenatória, conforme se depreende dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que procederam a abordagem do réu. As testemunhas ouvidas confirmaram o teor da denúncia, relatando que se depararam com o réu, já conhecido pelo envolvimento com tráfico de drogas, o qual estava parado na via pública, entregando algo ao motorista de um veículo de cor preta, que não foi identificado. O réu, ao notar a presença dos policiais, dispensou o que trazia na sua mão no chão, bem como o veículo deixou o local. Esclareceram que o réu foi abordado e feita a sua busca pessoal, em seu poder foi achada a soma de vinte reais. Realizada a vistoria no chão, localizaram três porções de maconha. Indagado acerca dos fatos e das drogas apreendidas, o réu admitiu iria vender uma das porções ao motorista do veículo e as demais comercializá-las na praça do bairro pelo valor de dez reais cada unidade. Acrescento que, relativamente aos depoimentos de agentes públicos, a jurisprudência sabiamente sedimentou a questão, reconhecendo o valor do depoimento daqueles, quando os autos não apresentem elementos que indiquem que tal prova não deva ser considerada. Ora, seria uma manifesta contradição o Estado credenciar agentes para atuar na área da segurança pública e investigar a prática de crimes e não acreditar em seus depoimentos em Juízo, cabendo lembrar que os policiais também são devidamente compromissados. Não se pode olvidar a presunção de lisura dos atos praticados por policiais, que, até prova em contrário (que nestes autos não foi produzida pelo réu), deve prevalecer. Aliás, nestes termos pronunciam-se os nossos

Pretórios: "O depoimento de policial militar, que efetuou a prisão em flagrante do agente, se reveste de especial valoração probatória pela premissa de que o servidor público, investido de autoridade, tem o dever funcional de contribuir para a apuração da verdade real e aplicação da lei penal" (STF - HC 119067 PR. Relator Min. LUIZ FUX. Julgamento: 28/08/2013. Publicação: DJe-171, 02/09/2013). "Neste compasso, ou seja, em relação à palavra dos policiais, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento." (STJ - AREsp 302955 SP 2013/0065939-3. Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJ 15/10/2014). Além da prova oral, outra circunstância que permite deduzir que as substâncias se destinavam à mercancia é justamente a quantidade e forma de acondicionamento, o que não deixa dúvida de que o réu se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes. Nestes termos, demonstradas a autoria e a materialidade da infração penal descrita na denúncia, a condenação do réu nos termos acima propostos, é medida que se impõe. No tocante à dosimetria, a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal. A ausência outras circunstâncias ou causas que poderiam interferir na dosimetria, a pena se torna definitiva. O regime adequado ao início do cumprimento da pena é o aberto. Diante de todo o exposto, aguardo seja a ação penal julgada PROCEDENTE para que o réu seja CONDENADO nos termos da denúncia, decretando-se o perdimento do valor apreendido, produto do tráfico. Dada a palavra à Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz: O Acusado responde por este juízo pela suposta prática de tráfico de entorpecentes. Após a regular tramitação do feito, foi colhido o depoimento das testemunhas. O réu foi citado e intimado, não compareceu ao ato processual e teve a revelia decretada. Finda a instrução, o i. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Sem razão, contudo. DA PROVA ORAL COLHIDA. A testemunha PM Fausto José de Mores narrou que o réu teria confessado informalmente a posse de drogas destinadas para tráfico e que tentava contato com um condutor que não foi identificado. A testemunha PM Rodolfo narrou que avistaram o réu conversando com alguém em condução de um veículo preto. O condutor não foi identificado nem abordado e o réu teria confessado os fatos. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. A) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. A acusação é improcedente e deve ser desclassificada para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Com efeito. Com efeito, o Acusado tinha em sua posse baixa quantidade de droga, qual seja, apenas três porções de maconha, com peso de 2,54g. Os policiais não presenciaram o réu fazendo contato com outras pessoas. Assim, não se tem como presumir que as drogas destinavam-se ao tráfico. Assim, requer a desclassificação do crime para a conduta descrita no art. 28, caput, da lei de Drogas e consequentemente seja declarada sua inconstitucionalidade, por violação ao princípio da vedação de punição à autolesão. B) DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Subsidiariamente, caso outro seja o entendimento do r. juízo, deve haver a absolvição da imputação de tráfico de entorpecentes, porque não há prova de traficância. Sobre a necessidade de prova segura da traficância, aplica-se o seguinte entendimento do Supremo Tribunal Federal: "O réu não tem o dever de demonstrar que a droga encontrada consigo seria utilizada apenas para consumo próprio. Cabe à acusação comprovar os elementos do tipo penal, ou seja, que a droga apreendida era destinada ao tráfico. Ao Estado-acusador incumbe demonstrar a configuração do tráfico, que não ocorre pelo simples fato dos réus terem comprado e estarem na posse de entorpecente. Em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, cabe ao Ministério Público comprovar que o entorpecente era destinado ao tráfico. Não fazendo esta prova, prevalece a versão do réu de que a droga era para consumo próprio". (STF. 1ª Turma. HC 107448/MG, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 18.6.2013 - Info 711). Não foi produzida, nestes autos, prova suficiente de que a droga apreendida se destinasse ao tráfico. Mesmo quando a droga é apreendida em grande quantidade (o que não é o caso dos autos), não se pode condenar sem prova da traficância. Neste sentido: "Sendo grande a

quantidade de tóxico apreendida, induz seu tráfico. Mas ninguém pode ser condenado por simples presunção, motivo por que para o reconhecimento do delito se exige prova segura e concludente da traficância" (TJSP, Ac. 35.505-3, rel. Silva Leme, RT 603/316). Ainda, é caso de absolvição diante da contaminação da prova. Conforme se verifica dos autos, não foi observada a incomunicabilidade entre as testemunhas de acusação, já que ambas estavam no mesmo ambiente. Percebe-se que além da fragilidade probatória, o rompimento de regra processual basilar que versa sobre a incomunicabilidade de testemunhas, o que também deve conduzir à absolvição do réu. Desta forma, conclui-se insuficiente a prova da acusação, sendo impositiva a absolvição. DOSIMETRIA. Superadas as teses de mérito e de desclassificação, devem ser observadas as seguintes questões no tocante à concretização da pena. Na primeira fase, a pena deve ser fixada no mínimo legal. Foi apreendido com o Autor apenas pouca quantidade de droga, substâncias que o réu faz uso. Desta forma, não estão previstas as circunstâncias de exasperação da pena base mencionadas no art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, incide a atenuante da idade do Acusado, que tinha somente dezoito anos na época dos fatos. Na terceira fase, deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Necessária a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu percentual máximo, eis que o acusado é primário, tem bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integram organização criminosa. "A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução da pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo" (STF, 2ª Turma, HC 103.225/RN, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 22/11/2011). Acerca da quantidade e qualidade da droga apreendida e a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, decidiu o STF que a: "Quantidade e qualidade da droga apreendida é circunstância que deve ser sopesada na primeira fase de individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo impróprio invoca-la por ocasião da escolha do fator de redução previsto no §4º do art. 33, sob pena de bis in idem" (STF, 2ª Turma, RHC 111.440/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/05/2012). Sobre o percentual aplicável: "O juiz, no exercício de suas funções judicantes, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado, deve fundamentar a não aplicação do percentual de 2/3 de redução, sob pena de violação do art. 93, IX, da CF/88, uma vez que é direito subjetivo do réu a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, desde que preenchidos os requisitos previstos no referido parágrafo" (STJ, 5ª Turma, HC 115.473/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 02/02/2009. REGIME INICIAL. Quanto ao regime inicial, nos termos do artigo 33 do Código Penal, requer seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena. Isso porque, a fixação de regime fechado como decorrência automática do disposto no artigo 2º da Lei n. 8.072/90 contraria o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do Habeas Corpus nº 111.840, em sessão realizada no dia 27 de junho de 2012, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603/SP assentou o entendimento de que condenados por tráfico privilegiado possuem direito subjetivo ao cumprimento da pena em regime inicialmente aberto. Destarte de rigor a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena. Cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o artigo 44 foi considerado inconstitucional pelo E. STF (HC n. 97.256/RS), o que motivou a expedição da Resolução n. 05, de 2012, do Senado Federal, suspendendo, nos termos do art. 52, X, da CF a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06" No mesmo sentido foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 596.603/SP. Diante do exposto, requer sejam acolhidas as teses defensivas, nos termos da fundamentação supra. Por

fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais, por se tratar de pessoa hipossuficiente nos termos da lei. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: GUSTAVO RICHARD BARBOSA FACHINI REGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 04 de fevereiro de 2021, por volta das 09:15hrs, na Rua Guapiara n. 27, Alambari, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 03 porções de maconha. O feito foi regularmente processado encerrando-se a instrução nesta data com alegações finais do MP e da Defesa. Eis, em síntese, o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal do réu no tocante à prática do delito de tráfico ilegal de entorpecentes. A materialidade restou incontroversa ante a apreensão da droga e o laudo acostado aos autos. O réu é revel. Os policiais declararam que em patrulhamento pelo local viram o réu entregando algo para o motorista de um veículo; que ao perceber a viatura, o motorista do veículo fugiu e o réu dispensou algo no chão; que ele foi abordado e verificado que ele havia dispensado três porções de maconha; que ele confirmou que estava vendendo cada porção por dez reais. Pois bem, finalizada a instrução, temos que o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu é responsável pela prática do delito; a assertiva é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito. A quantia de droga encontrada, as circunstâncias da prisão e a declarações do policial evidenciam a finalidade de tráfico. A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelo réu. Vale citar: "Adquirir, guardar ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288). Vale dizer que a lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Vale, ainda, mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos de policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesados em cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória." (Ap.Crim. 103.701 TJSP). " a simples condição de policial não torna a testemunha suspeita ou impedida" (STF - RT 68/64). " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Por outro lado, considerando que o réu é tecnicamente primário, é possível reconhecer a favor dele a causa de diminuição de pena do art. 33 parág. 4º, o que será feito no momento processual adequado. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e CONDENO o réu GUSTAVO RICHARD BARBOSA FACHINI REGO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06. Ante a condenação, custas pelo réu, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento em face dos benefícios da justiça gratuita deferidos nos autos. Fica decretado o perdimento dos bens e objetos apreendidos nos termos da Lei

de Tóxicos. DOSIMETRIA DA PENA. Atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal, a saber: CINCO ANOS DE RECLUSÃO

e multa de QUINHENTOS DIAS MULTA, cada qual no seu mínimo legal. Não existem circunstâncias agravantes. Presente uma atenuante decorrente da menoridade cuja consideração resta prejudicada em face da fixação da base em seu mínimo. Inexistem causas de aumento de pena. Presente uma causa de diminuição de pena, prevista no art. 33 parág. 4º da Lei 11.343/06, eis que o réu preenche os requisitos ali exigidos, diminuo em 2/3 a pena até agora calculada, chegando-se ao "quantum" de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO e multa de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA. Não havendo incidência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda torno DEFINITIVA A PENA DE UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO e multa de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Nos termos do art. 44 do Código penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE e MULTA DE DEZ DIAS MULTA. Ante a substituição retro operada, inviável a suspensão condicional da pena. Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena para o caso de conversão, o REGIME ABERTO. O réu foi colocado em liberdade no decorrer do feito e tal situação deve subsistir. Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, providencie-se o necessário para efetivo cumprimento da sanção imposta, arquivando-se o feito com as cautelas devidas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. Nada mais. Eu, ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA RAMOS, escrevente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA